



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 296/13

בענין:

1. יוסף יוסף
2. אילה מילר
- שניהם ע"י ב"כ עו"ד שילה ושות' עורכי דין
- משד' המגנים 35, חיפה
- ת.ד. 33691, חיפה 31336
- טל': 04-8535656, פקס: 04-8534545

התובעים

נגד

1. בת שבע דהן
- אהוד דהן
- ע"י ב"כ עו"ד אפרים מגיד ואח'
- מרח' טשרניחובסקי 27, חיפה 35701
- טל: 04-8339333, פקס: 04-8337444

2. נגר עוזי עזרא
- נגר רותי

3. אליאש חן
- אליאש טל

4. גולדמן עליזה
- מרח' הגליל 37א' חיפה

5. לנדסמן משה
- נתבעים מס' 3 – 5 ע"י ב"כ עו"ד ש. ברנקה-שוורץ
- מגדל המפרש, קומה 25
- ת.ד. 353, חיפה
- טל': 077-5444733, 077-5444700
- פקס: 077-5444777

6. זוסקינד ענתי
- זוסקינד טל

7. שקד יעקב
- שקד מלכה

- נתבעים 7 ע"י ב"כ עו"ד ש. ברנקה-שוורץ
- מגדל המפרש, קומה 25
- ת.ד. 353, חיפה
- טל': 077-5444733, 077-5444700
- פקס: 077-5444777

8. עדי אלי
- עדי רינת

הנתבעים

נתבעים מס' 2, 6, 8 מרח' סורוקה 20, חיפה

פ ס ק - ד י ן

1. עסקינן בבית משותף בן 6 דירות אשר במסגרת בנייה לפי תמ"א 38 חוזק מפני רעידות אדמה תוך הוספת 3 דירות חדשות לבית אשר שתיים מהן נמכרו האחת לתובעים (להלן: "יוסף") והשנייה לנתבעים מס' 1 (להלן: "דהן"). בין דהן לבין יוסף נתגלעו חילוקי דעות באשר לזכויות הקנייניות בשטחים המצויים בהיקף דירותיהם ובגין חילוקי דעות אלו הוגשה התובענה. היות וקיימת מחלוקת לגבי מעמדם המשפטי של מקצת השטחים נושא ההליך צורפו כצדדים נוספים להליך כל בעלי הדירות בבית כנתבעים מס' 2-8.

2. הבית נושא ההליך נמצא ברח' סורוקה 20, חיפה ומזוהה כחלק 73 בגוש 10797 (להלן: "הבית/הבית המשותף").

3. בתביעתם זו עתרו יוסף כי אורה לדהן כדלהלן: לפרק שער ברזל שהתקינו בשטח שאמור להיות שטח משותף ולהימנע משימוש ייחודי באותו השטח; לפרק חסימה של פתח שחרור עשן בחדר המדרגות בקומה 4; להסיר את מצלמות האבטחה שהציבו ברכוש המשותף; להסיט את יחידת מיזוג האוויר שהתקינו בסמיכות לחבלי הכביסה של יוסף למיקום התואם את מיקומה בתוכנית היתר הבניה.

רקע -

4. ביום 29.6.10 חתמו מי שהיו בעלי הדירות בבית המשותף על הסכם עם היזם "נורה יזמות בע"מ" (להלן: "הקבלן") ולפיו התחייב הקבלן לבצע חיזוק, שיפוץ, הוספת ממ"דים, מרפסות למעלית בבית בתמורה להעברת זכויות הבניה ליחידות נוספות שיבנה בבית המשותף.

5. בסעיף ההגדרות בהסכם הגדירו הצדדים את התמורה - "גג הבנין חלק מקומת העמודים, 3 מחסנים שייבנו בקומת הקרקע באזור המחסנים הקיימים, עליית הגג, גג הדירות החדשות וגג החדרים שעל הגג, חלק מהחצר עבור הקמת 3 חניות חדשות, זכויות הבניה הבלתי מנוצלות לרבות זכויות הבניה מכוח תמ"א 38... ובכפוף להותרת אזור מתוך שטח גג היחידות החדשות בשטח 80 מ"ר שיהיה רכוש משותף לכלל דיירי הבניין, ויגרע מזכויות היזם, אשר יועד למתקנים שונים לרבות דודים, קולטים..."

6. ביום 17.10.11 חתם הקבלן על הסכם מכר עם דהן בו התחייב למכור להם דירה אחת מתוך 3 הדירות שהוא מתעתד לבנות בבית במסגרת ההסכם שלו עם בעלי הדירות, וביום 30.10.11 חתם הקבלן על הסכם מכר עם יוסף בו התחייב למכור להם דירה אחרת מ-3 הדירות שהוא מתעתד לבנות בבית במסגרת ההסכם שלו עם בעלי הדירות. שתי הדירות מתוכננות היו להיבנות על גג הבית המשותף.

טענות יוסף-

7. יוסף טענו כי הסכם המכר קבע במפורש כי השטח המצוי בקדמת דירות יוסף ודהן יהיה שטח משותף והוא סומן ככזה גם בתשריטים שצורפו להסכמי המכר של אורן ויוסף. משכך דהן אינם רשאים להציב שער התוחם שטח זה לשימושם הייחודי.

8. לטענת יוסף לאחר קבלת טופס 4 סגר הקבלן לבקשת דהן פתח שחרור עשן בחדר המדרגות, וזאת בניגוד להוראות רשות כיבוי האש ובניגוד לתנאי היתר הבניה.

9. עוד טענו יוסף כי הקבלן התקין מזגנים בדירות דהן ויוסף אך דהן הזיזו את המזגן לאחר התקנתו בכ-30 ס"מ לכיוון חלון יוסף ובכך גרמו למטרד רעש, לכלוך וחום. המיקום החדש אינו תואם את המיקום המודגם בתוכנית שניתן לגביה היתר הבניה.

10. לסיום טענו יוסף כי דהן התקינו ברכוש המשותף על קיר חיצוני של הבית מצלמת וידאו במעגל סגור הצופה אל כניסת דירת יוסף ופוגעת בפרטיותם.

טענות דהן-

11. לגבי השטח בקדמת דירת דהן טענו דהן כי עפ"י הסכם המכר שנחתם בין בעלי הדירות בבית לבין הקבלן, הקבלן הוא בעל הזכויות בשטח זה וככזה מכר אותו לדהן. לטענתם חוזה המכר בין הקבלן לבין דהן קודם בזמן. משכך, היות והקבלן מכר לדהן שטח זה הרי שכאשר רכשו יוסף את דירתם כפופים היו לאותה מכירה ויש להכיר בזכותם של דהן באותו השטח אף מכוח דיני העסקאות הנוגדות המקנות יתרון לעסקה הקודמת בזמן.

12. עוד טענו דהן כי אמנם בתשריט שצורף לחוזה המכר הודגם השטח בקדמת דירתם כרכוש משותף אך בנספח ה' לחוזה המכר של יוסף נכללה הוראה מפורשת המוציאה מגדר הרכוש המשותף "שטחים מקורים ובלתי מקורים, לצורך שימוש כמעברים או כמבואות (לובי) או כרחבות כניסה ליחידות בבנין...", וכן נקבע כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים גוברות הוראות החוזה על התכניות ועל תשריט הדירה. לאור זאת גם לא הייתה כל מניעה לכך שהקבלן יבצע שינויים בהצמדות ויגדיל את שטח המרפסת שהוצמדה להם. אין לייחס למודגם בהיתר הבנייה משקל מכריע היות והיתר הבנייה משקף את המבוקש בפן התכנוני אך אינו יכול לגרוע מזכויות קנייניות שהוקנו. היות והשטח בקדמת דירת דהן נרכש על ידי דהן הרי שהתקנת השער שבוצעה על ידם היא כדין.

13. לטענתם אין כל יריבות בין דהן לבין יוסף בנוגע לפתח שחרור העשן באשר יוסף בעצמם כתבו בכתב תביעתם כי פתח זה נחסם ע"י הקבלן. לגופו של עניין טענו

דהן כי פתח זה לא נחסם והוא פתוח לשחרור עשן. לטענתם פתח שחרור העשן נבנה על די הקבלן במיקום שאינו תואם את תוכניות היתר הבניה וכתוצאה מכך נגרמה להם פגיעה בפרטיות, לאור זאת הקבלן התקין בחלקו התחתון של פתח זה לבני זכוכית על מנת למנוע אפשרות של כל עובר אורח לצפות לתוך חדר השינה בדירתם.

14. לגבי התקנת המזגן טענו דהן כי הוא הותקן ע"י הקבלן על גבי קיר חיצוני בדומה לכל יתר המזגנים בבית, וכי הטענות בנוגע אליו נטועות בדיני המטרדים ומשכך אינן בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.

15. לגבי המצלמה טענו דהן כי זו הותקנה בתוך מרפסתם על קיר שאינו "קיר חיצוני", נועדה לצלם את הכניסה לדירתם בלבד ואינה פוגעת בפרטיותו של איש. יוסף בעצמם ביחד עם בעלי דירות אחרים בבית התקינו מצלמה דומה בכניסה הראשית של הבית. לחילופין טענו דהן כי התקנתה עולה כדי שימוש סביר ברכוש המשותף שאינו טעון הסכמה.

ההליכים בתיק-

16. ביום 15.7.14 ביום 25.11.14 וביום 24.2.15 התקיימו דיוני הוכחות בתיק במסגרתם העידו מטעם יוסף הגב' לשניאק פולינה, האדריכלית שתכננה את הבניה, מר ואליד חמיס, הקבלן שביצע את הבניה והתובעים בעצמם. מטעם דהן העידה הנתבעת מסי' 1. נתבעים 2-8 ויתרו על העדת עדים מטעמם. חלקים מהעדויות יסקרו בפרק הדיון.

17. ביום 13.7.14 וביום 1.4.15 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) נמסר לי טרם עבודות הבניה לפי תוכנית תמ"א 38 לבית היו 3 קומות. בעקבות הבניה התווספו לבית, בין היתר, 2 הדירות נושא ההליך אשר משתרעות כל אחת על שתי קומות: קומה רביעית וקומה חמישית.

(ב) על אף העובדה שלכל אחת מדירות דהן ויוסף קיימות שתי כניסות: האחת מהקומה הרביעית והאחרת מהקומה החמישית, חדר המדרגות של הבית מוביל עד לקומה הרביעית בלבד. והמעבר בין המפלסים השונים בכל דירה נעשה באמצעות מדרגות פנימיות בתוך הדירה. במעלית הקיימת בבית ניתן לעלות רק עד למפלס התחתון בדירות דהן ויוסף והעלייה ממפלס זה למפלס הקומה החמישית אפשרית רק באמצעות מפתח אשר נתון בידי בעלי אותן דירות.

(ג) במפלס הקומה הרביעית בואכה דירות דהן ויוסף קיים מעבר המוביל אל דירות הצדדים להליך. במעבר, בצד הפונה לכיוון דירת דהן, קיים פתח שחרור עשן אשר בחלקו התחתון הותקנו לבני זכוכית המצמצמות כ-2/3 ממנו. הופניתי לכך שלבני הזכוכית נועדו לחסום את הנראות של חדר שינה בדירת דהן לעיני כל עובר אורח באותו מעבר.

(ד) במפלס הקומה החמישית קיים מסדרון המוביל מהמעלית לדירת יוסף ובהמשכו לדירת דהן. בהמשכו של הקיר המשותף המפריד בין דירת דהן לדירת יוסף התקינו דהן שער ברזל שגובהו המוערך עולה על 1.70 מ'. מעברו של שער זה קיימת מבואה הנמצאת בקדמת דירת דהן, רוחבה כ-3 מ' ואורכה כ-5.2 מ' (להלן: "השטח שבמחלוקת"). בהמשכו של השטח שבמחלוקת מצויה מרפסת דירת דהן המקיפה את הדירה מכיוון דרום ומכיוון מערב.

(ה) בשטח שבמחלוקת קיימת נקודת ניקוז המיועדת לנקז את השטחים הפתוחים באותה קומה. כן הופניתי לכך שאותה תאורה שהותקנה ע"י הקבלן במרפסת של דהן הותקנה על ידו גם בשטח שבמחלוקת.

(ו) בסמוך לדלת דירת דהן התקינו דהן מצלמת אבטחה הפונה לכיוון השער ומצלמת את מי שמגיע לדירת דהן. לאור גובהו של השער נראה כי כל אימת שהשער סגור לא ניתן לקלוט בעדשת המצלמה את המעבר המשותף המצוי מצפון לו.

(ז) דהן הפנו אותי אל שטח המצוי ממזרח לחדר המדרגות הפנים דירתי שלהם אשר עפ"י הנטען נגרע מהם במסגרת הבניה על מנת לאפשר יציאה לגג המשותף באמצעות סולם העלייה לגג.

(ח) בחדר האמבטיה של יוסף קיים חלון דרכו תולים יוסף כביסה על מתקן כביסה המותקן על הקיר החיצוני. בניצב לקיר עליו מותקן מתלה הכביסה קיים קיר של דירת דהן עליו מותקן מנוע מזגן המשמש את דהן והוא ממוקם בסמוך למתקן הכביסה. מנוע המזגן משחרר אויר במקביל לכיוון מתלה הכביסה ולא לעברו. סלע המחלוקת בין הצדדים הוא האם יש להסיט את מנוע המזגן דרומה בכ-30 ס"מ או להותירו על מכונו.

(ט) הופניתי אל המיקום של סולם העלייה לגג עפ"י התכנון המקורי, בסמוך לכניסה לדירת דהן, ואל מיקומו בפועל בסמוך ליציאה מהמעלית.

18. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ וכעת כל שנוטר לי הוא להכריע בסוגיות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

19. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה ולהורות על הסרת השער והמצלמה. להלן יפורטו נימוקי החלטתי.

שטח המחלוקת-

20. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר רכוש משותף באופן שיורי ככולל את כל חלקי הבית המשותף פרט לאלה שנרשמו כדירות ובהעדר הוראה אחרת הוא כולל, בין היתר, גם את גגות הבית המשותף (ראו: יהושע ויסמן **דיני קניין – בעלות ושיתוף** 392 (1997); ע"א 11965/05 **עזבון קליין נ' שרון**, [פורסם בנבו] פסקאות 32-33 לפסק דינה של השופטת מ' נאור (27.8.2009)).

21. בהתאם לסעיף 55 לחוק המקרקעין לכל דירה בבית המשותף מוצמד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו הבית, אלא אם כן קבעו בעלי הדירות בתקנון הבית המשותף כי חלק מסוים יוצא מן הרכוש המשותף ויהיה צמוד לדירה פלונית. הרכוש המשותף, אפוא, כשמו כן הוא – הוא שייך במשותף לכלל בעלי הדירות בחלקים יחסיים ובלתי מסוימים הקבועים בצו הבית המשותף (ראו: סעיף 57 לחוק המקרקעין; אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** חלק שלישי – בתים משותפים 90 (2001)). זאת אלא אם כן הוצא חלק מסוים ממנו והוצמד כחוק לאחת הדירות.

22. סעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק המכר (דירות)"), קובע את התנאים שבהם נדרש לעמוד מוכר דירה, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, אם ברצונו להוציא חלקים מן הרכוש המשותף. וכך קובע הסעיף:

"(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה העניינים:

- (1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
- (2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
- (3) [...]
- (4) [...]
- (5) [...]

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף."

23. מוכר דירה, ובענייננו – הקבלן, המבקש להוציא חלקים מן הרכוש המשותף חייב, אפוא, ליתן לכך ביטוי מפורש וברור במפרט המצורף להסכם המכר או לצרף לחוזה המכר פירוט מדויק המתייחס לאותם חלקים. הסעיף נועד לוודא כי הזכויות אותן רוכש הקונה לא רק הובאו לידיעתו אלא גם הובנו על-ידו, ולמנוע מצב בו המוכר מסתיר את כוונותיו האמיתיות מאחורי אמירות כלליות וניסוחים מעורפלים או על-ידי "הבלעת" עניינים מהותיים להתקשרות אשר להם משמעות כספית חשובה (ראו: ע"א 118/78 **גוב ארי חברה לבנין ולהשקעות בע"מ נ' כהן**, פ"ד לג(1) 805, 812 (1979); ע"א 60/80 **שטרן נ' מאירי יצחק חברה קבלנית לבתיים משותפים לבנין בע"מ**, פ"ד לו(3) 48, 54 (1982); ע"א 3017/92 **מרדר נ' כרמלי**, [פורסם בנבון] פס' 4(ג) (7.8.1995)).

24. בע"א 213/80 **שמעונוף נ' ברוכים**, פ"ד לז(3) 808 (להלן: "שמעונוף"), עמד כב' השופט אלון בעמ' 813 על מטרתו של חוק המכר (דירות) ועל הצורך בהקפדה יתרה עם הקבלן – בקטנה כבגדולה – בכל הנוגע לקיום דרישותיו של החוק:

"מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת – וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות ומבלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות כספית חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים – מה הן כוונותיו האמיתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו ... כדי להבטיח שאכן הובאו הדברים לידיעת הקונה והובנו על-ידו, חובה היא על המוכר לצרף לחוזה מיפרט, ובו תיאור הדירה וכל הכלול בה ... ואם מבקש המוכר לשנות מן התקנון המצוי בקשר לזכויות שבבית המשותף, חייב שינוי זה להופיע במפורש במיפרט הנ"ל או במסמך המצורף לחוזה ובו פרטים בקשר לשינוי זה. ייחוד והבלטה אלה מטרתם להסב את שימת לבו של הקונה לשינויים אלה. הצורך בהגנה מיוחדת זו על קונה הדירה נובע ממעמדו הנחות של הקונה מבחינת כוח המיקוח, יכולת התמרון וניסוח החוזה לעומת הקבלן בונה הדירה, וזאת כאשר מדובר במצרף חיוני ביותר, הן לפרט והן מבחינת האינטרס הציבורי והחברתי, ובסכומי כסף ניכרים וגדולים".

וראו בעניין זה גם דברים דומים שנאמרו בע"א 238/83 **נציגות הבית המשותף נ' מרכוס**, פ"ד מא(2) 561.

25. עוד קבעה הפסיקה כי גריעה מהשטח המשותף חייבת להיעשות באופן קונקרטי ומפורש בכתובים. אין די בקיום הוראה כללית בחוזה המכר המותירה בידי הקבלן המוכר שיקול דעת לגרוע בעתיד שטחים מהרכוש המשותף בלא פירוט קונקרטי של שטחים מוגדרים. תיאור החלקים המוצאים מהרכוש המשותף צריך אפוא להיות מדויק ומפורט (ראו רע"א 259/99 **חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385, בעמ' 402; ע"א 3902/98 **מיאב חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' סטולר**, פ"ד נד(1) 849, בעמ' 858; וכן: מ' דויטש, **קנין**, כרך א' 684).

26. האם עמד הקבלן בחובותיו אלו במסגרת הסכמי המכר שחתם עם בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות עם הצדדים להליך?

27. לצורך כך ייבחן החוזה שחתם הקבלן עם בעלי הדירות בבית.

28. ביום 29.6.10 נחתם בין נתבעים 2-8 (או בין מי שהיו בעלים קודם בדירותיהם) לבין הקבלן הסכם "לחיזוק, שיפוץ והוספת ממ"דים ושטחי בניה נוספים ומרפסות ומעלית בבנין בתמורה להעברת זכויות הבניה ליחידות דיור נוספות בהתאם להוראות תמ"א 38". השאלה הראשונה אליה אדרש היא האם במסגרת אותו הסכם רכש הקבלן מנתבעים 2-8 את הזכויות בשטח המחלוקת. עמדתם של נתבעים 2-8 בשאלה זו הייתה שאין להם כל עניין בשטח המחלוקת היות ושטח זה אינו נמנה על השטחים שנותרו בבעלותם עפ"י החוזה בינם לבין הקבלן. ראו בעניין את סכום טענות הנתבעים בעמ' 75 לפרוטוקול שורות 33-37, בעמ' 76 שורות 15-16 ובעמ' 76 שורות 33-34. אליבא דידם אין להם עניין במחלוקת בין הצדדים, קרי, בשאלה האם הקבלן היה רשאי להעביר שטח זה לחזקת דהן או להותירו רכוש משותף. מתוך חוזה המכר שנחתם בין נתבעים 2-8 לבין הקבלן ראוי לציטוט בהקשר זה סעיף 1 ג. הקובע כדלהלן:

סעיף 1 ג. "התמורה -גג הבנין, חלק מקומת העמודים, 3 מחסנים שייבנו בקומת הקרקע באזור המחסנים הקיימים, עליית הגג, גג הדירות החדשות וגג החדרים שעל הגג, חלק מהחצר עבור הקמת 3 חניות חדשות, זכויות הבניה הבלתי מנוצלות לרבות זכויות הבניה מכוח תמ"א 38, לבניית 3 יחידות דיור נוספות (אחת בקומת הקרקע ו-2 על גג המבנה הקיים) - והכל בהתאם לאמור בהסכם זה וסעיפים 6 ו-8 וסעיף 8 וכן לתוכניות המפורטות כנספח ד' להסכם זה ובכפוף ל: א. הותרת אזור מתוך שטח גג היחידות החדשות בשטח 80 מ"ר שיהיה רכוש משותף לכלל דיירי הבנין, ויגרע מזכויות הקבלן, אשר יועד למתקנים שונים לרבות דודים, קולטים..."

29. מהסעיף הנ"ל וכן מעמדת ב"כ הנתבעים 2-8 עלה כי בכפוף להותרת שטח של כ- 80 מ"ר על הגג לטובת הצבת מתקנים משותפים ושמירת גישה ישירה ונוחה אליהם ויתרו הנתבעים על שטחי הגגות לרבות על שטח המחלוקת.

30. נקודת המוצא היא, אם כן, שבשלב בו חתם הקבלן על חוזה המכר עם הצדדים להליך שטח המחלוקת הוקנה למעשה לקבלן ע"י כל בעלי הדירות בבית באותו המועד.

31. נדרש, אם כן, שאבחן האם יש אינדיקציות לכך שהקבלן הצמיד את שטח המחלוקת או חלקים ממנו לדהן ואם כן האם הדבר נעשה כדין?

32. ביום 17.10.11 נחתם חוזה המכר בין דהן לקבלן (להלן: "חוזה דהן-קבלן"), ולאחריו ביום 30.10.11 נחתם חוזה המכר בין יוסף לקבלן (להלן: "חוזה יוסף קבלן").

33. בתשריט שצורף לחוזה המכר דהן-קבלן רשום על גבי שטח המחלוקת "שטח משותף" אך על אף הרישום כמחצית משטח המחלוקת הוקף בצבע כתום וסומן כהמשכה של המרפסת שהוצמדה לדירת דהן, וזאת ללא שנמחקו מהתשריט המילים "שטח משותף". לגבי יתרת שטח המריבה טענה דהן כי זה הובטח לה בע"פ על ידי הקבלן.

34. הגב' דהן העידה בעמ' 53 לפרוטוקול שורה 39 ואילך והמשך בעמ' 54 :

"מכיון שאני חתמתי את החוזה, אני הראשונה שקניתי שם בית, אני הבנתי ממה שהקבלן אמר לי בצורה מאד ברורה זה שאין לו כל מניעה/הגבלה לעמוד בתנאי החוזה שלי ולתת לי בדיוק מה שקניתי כי הוא לא מכר עדיין שום דבר לאף אחד." (הדגשה שלי י.ל.)

וראו עדות דומה בעמ' 59 לפרוטוקול שורות 3-5.

35. עמדתה זו של דהן ולפיה היות והקבלן היה בעלים של שטח המחלוקת לא הייתה מניעה לכך שיקנה לה שטח זה אף במועד מאוחר לחוזה תיבחן על רקע החוזים השונים שנחתמו בין הקבלן לצדדים להליך.

36. החוזה עם יוסף נחתם, כאמור, בשלב מאוחר יותר, אך בתשריט שצורף לאותו חוזה נכתב בידי הקבלן על גבי כל שטח המחלוקת "שטח משותף" והודגמה המרפסת שהוצמדה לדירת דהן ככזו המתחילה בשולי שטח המחלוקת ואינה כוללת חלק ממנו.

37. יוסף טענו כי רכשו את דירתם תוך שהם מסתמכים על התשריט בו כל שטח המחלוקת מופיע כ"רכוש משותף". משכך, לטענתם, לא ניתן ליתן משקל כלשהו להתחייבויות שנתן הקבלן לדהן, אם נתן, להוציא את שטח המחלוקת מכלל הרכוש המשותף ולהצמידו לדירתם.

38. לטעמם גם העובדה שחוזה המכר דהן-קבלן נחתם לפני חוזה המכר שלהם אין בה כדי להעלות או להוריד מקום בו הוראה דומה לא נכללה בחוזה עימם.

39. אסקור להלן סעיפים נבחרים מתוך החוזים שנכרתו בין הקבלן לדהן וליוסף.

40. במבוא להסכם ב-"והואיל" השישי לחוזה דהן-קבלן נקבע מה יוצמד לדירה וכך נקבע:

"לדירה זו יוצמדו חניה המסומנת בצבע כתום מחסן המסומן בצבע כתום וגג המסומן בצבע כתום." (הדגשה שלי י.ל.)

41. בסעיף 2 לאותו חוזה בפרק ההגדרות בהגדרת "הדירה" נקבע:

"יובהר כי השטח המסומן בתוכנית כמשותף בקומה 5 ביציאה מהמעלית ישמש אך ורק כאמצעי עלייה לגג באמצעות סולם בלבד. כל יתר שטח מפלס קומה זו יהווה חלק מ 7 או 8. השטח המשותף על גג קומה חמישית, ישמש את כלל דיירי הבניין לטובת דודי שמש קולטים ובאחריותם תהא התחזוקה שוטפת של הגג. יובהר כי המרפסת המסומנת בכתום בתשריט המצורף, הינה בשטח הגדול בכ-12 מ"ר מהמאוסר בהיתר הבניה. המוכר יפעל ככל שיתאפשר להכללת שטח זה במסגרת תיקון צו הבית המשותף."

42. בסעיף 26.3 לחוזה המכר דהן-קבלן ניתנה לקבלן הסמכות לעשות כדלהלן:

" להוציא מהרכוש המשותף איזה שטחים שהם, בהתאם לשיקול דעתה בלעדי ולעשותם יחידות רישום נפרדות ו/או להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם ליחידות דיור בבית או ליחידות נפרדות אחרות או לרשום בכל דרך אחרת את היחידות ו/או השטחים הנ"ל ובלבד שלא תפגע יחידת הדיור עצמה ולא יגרעו או יפגעו ההצמדות לה, אם קיימות במפורש בנספח ד'."

43. החוזה, אם כן, כולל הן הוראה קונקרטית המתייחסת להגדלת שטח מרפסת דהן והן סמכות כללית רחבה לקבלן להוציא שטחים ככל שיחפוץ בהתאם לשיקול דעתו.

44. על אף היות החוזה דהן-קבלן כמעט זהה לחוזה יוסף-קבלן, בוטלו בחוזה יוסף-קבלן הסעיפים שצוטטו לעיל. בסעיפים נוספים שיובאו להלן קיימים שינויים בין החוזים שנחתמו בין הצדדים להליך, כפי שיפורטו להלן.

45. בסעיף 28.9 לשני חוזי המכר נקבע כדלהלן:

"מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, והוראות נספח ה' לחוזה זה, יהיה המוכר זכאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להוציא חלקים מהרכוש המשותף, כמפורט להלן- בין שהם חלקים מהבנין או מהבניינים שייבנו בחלקה ובין שהם חלקים מהחלקה, שיוותרו מחוץ לבנין או לבניינים שייבנו בה ולהצמידם לכל יחידה או למספר יחידות שייבנו בבנין ו/או בחלקה, בשלמות ו/או בחלקים, דהיינו:

28.9.1 מחסנים.

28.9.2 חניות (מקורות ובלתי מקורות).

28.9.3 שטחי קרקע לגינות.

28.9.4 גגות, לרבות חלק מהגגות המשמשים כמרפסות ליחידות הבנין.

28.9.5 שטחים מקורים ובלתי מקורים כמעברים ו/או כרחבות כניסה ליחידות בבנין.....

46. בחוזה המכר דהן-קבלן ניתנה לקבלן סמכות רחבה להוציא שטחים ככל שיחפוץ מהרכוש המשותף, וכך נקבע בסעיף 28.33 כדלהלן:

"כמו כן מאשר הקונה כי עיין בתשריט המצורף כנספח ה' לחוזה (נספח הוצאות שטחים מהרכוש המשותף) וידוע לו כי השטחים המסומנים בו כשטחים שיוצאו מהרכוש המשותף, אינם ממצים ואינם משקפים את כל השטחים שהמוכר זכאי להוציא מהרכוש המשותף." (הדגשה שלי י.ל.)

בהמשך נקבע בסעיף 28.34 לחוזה המכר בין דהן לקבלן כי:

"ידוע לקונה כי המוכר זכאי להוציא מהרכוש המשותף אל כל השטחים שפורטו בנספח ה' לחוזה, גם אם לא תוארו בתשריט שצורף לנספח ה' לחוזה או גם אם תוארו בו, בין שהדבר ניתן להעשות ובין שאינו ניתן להעשות ולא תהיינה לו כל טענות עקב כך." (הדגשה שלי י.ל.)

47. להבדיל מסעיף 28.30 לחוזה המכר יוסף-קבלן שהוא מקביל של סעיף 28.34 לחוזה דהן-קבלן שונה הסעיף באופן המצמצם את סמכויותיו של הקבלן ומקנה משקל משמעותי לתשריט שצורף לחוזה המכר. וכך קבע הסעיף:

"כמו כן מאשר הקונה כי עיין בתשריט המצורף כנספח ה' לחוזה (נספח הוצאות שטחים מהרכוש המשותף) וידוע לו כי השטחים המסומנים בו כשטחים שיוצאו מהרכוש המשותף, ממצים משקפים את כל השטחים שהמוכר זכאי להוציא מהרכוש המשותף." (הדגשה שלי י.ל.)

48. בנוסף בהסכם יוסף בוטל הסעיף המקנה למוכר (הקבלן) את הזכות להוציא מהרכוש המשותף שטחים שלא תוארו בתשריט שצורף לנספח ה'.

49. ועוד, בנספח ה' לשני חוזי המכר שנחתמו פורטו השטחים המוצאים מהרכוש המשותף וכך נקבע באותם הסעיפים הבאים:

4. "מובהר כי מוכר יהיה רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי, את מיקום וסימון חלק משטח החצר, הלובי, המעברים והגג (אשר חלקים מהם בלבד יועדו להצבת מתקני הבית המשותף ואשר ירשמו כרכוש משותף וישמשו למטרה זו) והכל בכפוף לכל דין. יתר השטחים בגג, בחצר, בלובי, בחניונים וכיו"ב, לא יכללו בגדר הרכוש המשותף וישארו בבעלותו הבלעדית של המוכר."

5. למען הסר ספק, השטחים המפורטים להלן, לא יכללו בגדר הרכוש המשותף, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת על ידי המוכר:

.
.
.

(5) שטחים מקורים ובלתי מקורים לצורך שימוש כמעברים או כמבואות (לובי) או כרחבות כניסה ליחידות בבנין. (ודוקו: בחוזה יוסף-קבלן נוספו בהמשכו של ס"ק זה המילים "כמפורט בתוכנית נספח א'." (הוא התשריט שצורף לחוזה המכר)).

.
.
.

(10) כל שטח אחר או שלא נקבע לגביו במפורש כי הוא מהווה חלק מהרכוש המשותף ואינו מהווה רכוש משותף הכרחי. (בחוזה יוסף-קבלן בוטל ס"ק זה).

50. עינינו הרואות כי יוסף עמדו על כך שלתשריט, הוצג וסומן ת/7, יהא משקל מכריע והוא יגבור על הוראות נספח ההצמדות, והם ביטלו את אפשרותו של הקבלן להוציא שטחים שזכרם לא בא באותו התשריט.

51. ובהמשך, לאחר פירוט החלקים המוצאים מהרכוש המשותף בנספח ההצמדות קיימת בכל אחד מהחוזים תוספת שונה לסעיף. בחוזה דהן-יוסף מופיעה התוספת הבאה:

"לנספח זה מצורף כחלק בלתי נפרד הימנו תשריט המתאר בין היתר את שטחי החניות, המחסנים ושטחי החצר המוצאים מן הרכוש המשותף ומובהר להסרת ספקות, כי התשריט הוא לצרכי נוחיות בלבד ואינו ממצה את כל השטחים שהמוכר רשאי להוציא מהרכוש המשותף, כמפורט בסעיף דלעיל. (הדגשה שלי י.ל.)

בחוזה יוסף-קבלן לעומת זאת קיימת תוספת שונה הקובעת כי התשריט הוא המחייב בקביעת החלקים שהוצאו מהרכוש המשותף:

"לנספח זה מצורף כחלק בלתי נפרד הימנו תשריט המתאר בין היתר את שטחי החניות, המחסנים ושטחי החצר המוצאים מן הרכוש המשותף ומובהר להסרת ספקות, כי התשריט הוא משקף את השטחים המוצאים מהרכוש המשותף וממצה את כל השטחים שהמוכר רשאי להוציא מהרכוש המשותף, כמפורט בסעיף דלעיל. (הדגשה שלי י.ל.)

52. מאחר וחוזה דהן קדם בזמן לחושה יוסף נראה כי השוני בין הסעיפים הוא תוצאה של מו"מ בין הצדדים. אמנם בחוזה דהן-קבלן הותיר בידיו הקבלן אפשרויות בלתי מוגבלות להוצאת שטחים מהרכוש המשותף מעבר לאלו

המודגמים בתשריט שצורף להסכם המכר, אך בחוזה יוסף-קבלן עמדו יוסף על כך שירשם בחוזה מפורשות כי התשריט שצורף להסכם המכר ממצה את השטחים שהקבלן רשאי להוציא מהרכוש המשותף.

53. נמצא, אם כן, כי קיימים שני חוזי מכר הסותרים בתוכנם האחד את השני. בתשריטים שצורפו לחוזי המכר מודגם שטח המחלוקת באופן שונה וגם בחוזה על נספחיו קיים שוני בכל הנוגע ליכולותיו המוגבלות/בלתי מוגבלות של הקבלן להצמיד גם לאחר מועד החתימה על חוזי המכר שטחים נוספים לדירות, שטחים שלא סומנו בתשריט לצורף לחוזי המכר.

54. פשיטא שרוכש סביר המעיין בחוזה המכר יוסף-קבלן על נספחיו, ובמיוחד בסעיפים שבוטלו או שונו ע"י הקבלן, יכול להתרשם כי יוסף עמדו על כך שהתשריט שצורף לחוזה עימם יחייב, שהשטחים המסומנים בו כשטחים שיוצאו מהרכוש המשותף, ממצים, ושהקבלן לא יהא רשאי להוציא שטחים נוספים על אלו המודגמים באותו תשריט מגדר הרכוש המשותף.

55. לטעמי, על ההוראות הכלליות בחוזה יוסף-קבלן המאפשרות לקבלן להוציא חלקים מרכוש המשותף כראות עיניו גוברות ההוראות הקונקרטיות המפורטות בסעיף 28.30 ובסיפא לסעיף 5 בנספח ה' לחוזה יוסף-קבלן. גם מביטולם של סעיפים כמפורט לעיל אשר ביקשו להקנות לקבלן אפשרויות בלתי מוגבלות ביחס לשטחים המשותפים ניתן ללמוד כי הם לא היו מקובלים על יוסף. הללו משקפים את אומד דעת יוסף במועד רכישת דירתם על כך שהחלקים שהודגמו בתשריט שצורף לחוזה שלהם (ת/7) כחלקים משותפים יוותרו ככאלו.

56. היוצא מן האמור לעיל הוא, כי למצער ביחס ליוסף לא עמד הקבלן בדרישות סעיף 6(א) לחוק המכר (דירות). למעלה מהדרוש יצוין כי גם מעדות הקבלן עלה כי השטח המצוי בין המעלית לבין הקיר שסומן בצבע צהוב בתשריט ת/4 הוא שטח משותף וכך אף הודגם בהיתר המכירה ובכל החוזים, ראו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 21-28. עוד העיד הקבלן כי לא עדכן את יוסף בע"פ או בכתב בדבר כוונותיו להעביר לדהן חלק משטח המחלוקת, ראו עדותו בעמ' 17 לפרוטוקול שורות 24-27.

57. מהי המשמעות המשפטית של מסקנה זו?

58. משנמצא כי נתבעים 2-8 ויתרו על שטח המחלוקת, ועל כך אין חולק, הפך שטח זה לרכוש משותף חלקי, הצמוד בצמידות משותפת לבעלי הדירות הצדדים להליך (ראו התייחסות לרכוש משותף חלקי בספרו של י. ויסמן, **דיני קניין, בעלות ושיתוף**, כרך שני בעמ' 400). ביחסים בין הקבלן לבין הצדדים להליך, אשר ביחס אליהם שטח המחלוקת משותף הוא, משעה ש"נפגמה" החרגתו של חלק

מהרכוש המשותף ביחס לפלוני, רואים אותה מניה וביה כפגומה גם ביחס לכל היתר.

59. נמצא כי אפילו יוכיחו דהן כי הקבלן התחייב להצמיד להם את שטח המחלוקת, הלכה היא, כי מקום שלא ניתנה הסכמה הולמת לכך מאחד מבעלי הדירות בבית, לענייננו, מיוסף, די בכך על מנת שמערך ההצמדה כולו יתמוטט. עמדה על כך כב' השופטת נתניהו בע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' מרכוס פ"ד מא(2) 561, בעמ' 569 :

"משמעות הדברים היא, שאפילו נכללה הוראה מפורשת בחוזים שבין הקבלן למשיבים, המוציאה את המעלית מהרכוש המשותף ... עדיין יש לבחון, אם קוימו הוראות חוק המכר (דירות) כלפי כל יתר רוכשי הדירות. די יהיה בכך אם לא קוימו רק כלפי אחד מהרוכשים כדי להכשיל את ההתחייבות כלפי המשיבים, ואזי, על-פי סעיף 6(ב), יראו את הקבלן כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי יחולו על הבית המשותף."

וראו בעניין גם את ספרו של דויטש, קניין, בעמ' 687.

60. הטעם העומד ביסודה של הלכה זו הוסבר בפרשת שמעון, וראוי להביאו כלשונו :

"הלכה נקוטה בידינו, כי משנקבע ביחסים שבין המוכר-הקבלן לבין אחד הקונים-הדיירים, כי רכוש מסוים שבבית רכוש משותף הוא, חלה קביעה זו מאליה ובאופן אוטומטי לעניין רכוש מסוים זה גם לגבי היחסים שבין יתר הקונים-הדיירים שבאותו בניין לבין הקבלן-המוכר."

ובהמשך פסה"ד-

"הנימוק שביסוד הלכה זו הוא למנוע אנדרלמוסיה ובלבול ביחס לאופיים של השטחים השונים שבבית המשותף, כלומר למנוע מצב שאותו שטח עצמו, בעת ובעונה אחת, ממין מבחינה משפטית בצורות שונות, הסותרות אחת את רעותה, היינו, שביחסים שבין הדייר ראובן לבין הקבלן שטח זה הוא מוצמד, וביחסים שבין הדייר שמעון לבין הקבלן אותו שטח עצמו הוא רכוש משותף."

61. זאת ועוד, לאור הרציונל העומד מאחורי סעיף 6 לחוק המכר (דירות) אין מקום להחיל את דיני העסקאות הנוגדות על סיטואציות כאלו, ואין ליתן כל יתרון לחוזה שנערך בין דהן לבין הקבלן משום היותו קודם בזמן. וראו בעניין זה את האמור בספרו של דויטש, קניין, כרך א' עמ' 690 ואילך.

62. דהן פירטו באריכות בעדויות את השתלשלות היחסים וההתחייבויות בינם לבין הקבלן ואת התמורות השונות שנתנו לו כנגד התחייבותו להצמיד להם את שטח המחלוקת. ואולם, משעה שהגעתי למסקנה כי התחייבות הקבלן כלפיהם אינה

יכולה לחייב את יוסף, אשר בחוזה המכר שלהם הודגם שטח המחלוקת כרכוש משותף, אין עוד משמעות וטעם להידרש לשלל העדויות בעניין.

63. חיזוק לאמור מוצאת אני בעמדת הקבלן כפי שהיא באה לידי ביטוי בעדותו ובמכתב שהפנה לדהן, שם מבהיר הקבלן כי לשם הצמדת השטח שבמחלוקת לדהן תידרש הסכמת כל בעלי הדירות בבית. וזו עדותו בעניין בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 20-41 :

"אני רציתי שהשטח הזה כן יעבור למרפסת הנתבעים. ולמרות שלא קיבלתי על זה שום תשלום וגם לא ביקשתי. אבל על מנת לעשות את זה באופן חוקי היה נדרש לקבל את הסכמתם של כל 9 הדירות הקיימות בבית מאחר ומדובר בשטח משותף...הנתבעים מעולם לא נתנו את הסכמתם לכך, תמיד התנגדו."

וראו גם עדותו בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 39-40 :

"קיווייתי שבסופו של תהליך אוכל להצמיד את השטח הזה (-השטח שבמחלוקת, הוספה שלי י.ל.) לנתבעים אך ללא הסכמת הדיירים הדבר לא נעשה."

64. וכן במכתב מייל שהפנה הקבלן לדהן (הוגש וסומן נ/10) :

"ככל שתלוי בי אשתדל ואעשה הכל לצרף את השטח הנחשב למשותף ע"י הכניסה לדירתך אלייך...אך ברצוני להדגיש שוב כי השטח הזה הוא לא שלי אלא של בעלי הדירות, ולכן צריך את הסכמתם לכך."

65. מרגע שיוסף עומדים בסירובם להצמיד את שטח המחלוקת או חלקים ממנו לדירת דהן גם אין טעם להידרש לראיות שהוגשו בנוגע להסכמות מאוחרות שנתנו נתבעים 2-8 להצמדת שטח המחלוקת וחזרתם מהסכמות אלו. כפי שפורט לעיל מרגע ש"נפגמה" החרגתו של חלק מהרכוש המשותף בחוזה יוסף-קבלן ממילא לא ניתן עוד לבצע הצמדה זו לדירת דהן, וזאת ללא כל קשר לעמדת יתר בעלי הדירות בבית.

66. הפועל היוצא של האמור הוא שהשער שהותקן בשטח משותף, מהווה שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף ויש להורות על הסרתו.

67. טרם סיום פרק זה אציין כי לא נעלמה מעיניי הפנייתם של דהן לע"א 750/88 רובינשטיין אברהם ושות', חברה קבלנית בע"מ נ' אגמי (פורסם ביום 27.11.90 (להלן: "רובינשטיין"), מתוכו בחרתי לצטט את הדברים הבאים :

"הרי שבענייננו קבע המיפרט מפורשות, כי שטח הגג (ובו החלקה נושא מחלוקת) מוצא מהרכוש המשותף, וכי ניתן יהיה להצמידו לדירות ספציפיות. כל זא-בבירור, במובלט, לא ב"אותיות קטנות". לא הייתה כאן גריעה כוללת מכלל הרכוש המשותף, כזה שמקובל להצמידו וכזה שאינו מקובל. אלא זכות ההצמדה צומצמה אך ורק לשטחי החניה והגגות.... מפסק הדין של הערכאה הראשונה, לו נותר על כנו, עלול היה להשתמע, כי על מנת לעמוד בדרישת הפירוט שבסעיף 6 הנ"ל לא די לפרט בחוזה ובמיפרט אילו חלקים מוצאים מכלל הרכוש המשותף, אלא גם יש לציין בכל חוזה וחוזה (או מיפרט) לאיזו דירה ספציפית מוצמד כל חלק המוצא מן הרכוש המשותף. דרישה מעין זו לא בא זכרה בחוק ובפסיקה ואף אין היא רצויה. יש בה משום כבילה מכבידה ומיותרת של הקבלן, מבלי שתצמח מכך תועלת ממשית לקונה. הדירות בבית המשותף נמכרות באופן הדרגתי, ופעמים רבות מתקשר הקבלן עם רוכש אחד שעה שאין הוא יודע ואינו יכול לדעת מה תהא עמדת רוכשי דירות עתידיים באשר להצמדת חלקים שמקומם ברכוש המשותף דוגמת חניה או גג לדירותיהם. אשר לרוכשי הדירה הראשונים, דיים שפורט והובא לידיעתם בחוזה הרכישה ובמיפרט (כפי שנעשה הדבר במקרה דנן), אילו חלקים הוצאו מהרכוש המשותף במטרה להצמידם לדירות ספציפיות בעתיד. בכך ניתנה להם ההגנה הנדרשת. אין עניינם בשאלה, למי מן הדיירים יוצמדו אותם חלקים, בוודאי כל עוד אין באותה הצמדה דבר החורג מן הרגיל והמקובל."

68. בשונה מפס"ד רובינשטיין שם נכללה בכל החוזים הוראה אחידה המוציאה את השטחים נושא אותו הליך מהרכוש המשותף, בחוזים נושא ההליך, כפי שפורש לעיל, לא קיימת אחידות בפירוט החלקים המוצאים מהרכוש המשותף. ודוק-בעוד שבחוזה דהן-קבלן הוציא הקבלן מגדר הרכוש המשותף במפורש את השטחים המקורים והבלתי מקורים לצורך שימוש במעברים, הרי שבחוזה יוסף-קבלן נרשם מפורשות כי על אף נספח ההצמדות בו רשום כי הקבלן רשאי להוציא מהרכוש המשותף את השטחים המקורים והבלתי מקורים לצורך שימוש במעברים, דווקא התשריט שצורף לחוזה משקף וממצה את השטחים המוצאים מהרכוש המשותף, ובאותו תשריט נרשם באופן מפורש, שחור על גבי לבן, כי שטח המחלוקת הוא שטח משותף.

69. לאור האמור, בנסיבות תיק זה, בשונה מפס"ד רובינשטיין, לא מצאתי כי הקבלן הוציא בחוזה שלו עם יוסף את שטח המחלוקת מגדר הרכוש המשותף או כי הותיר בידיו את האפשרות לעשות בו כראות עיניו, אלא מהחוזה של דהן על נספחיו עולה אומד דעת יוסף, אשר באה לידי ביטוי מפורש בחוזה עימם, ולפיו הקבלן ביטל וצמצם את אפשרותו זו והגביל את עצמו לאמור בתשריט שצורף לחוזה עימם.

70. לאור האמור אני מורה לדון להסיר את שער הברזל שהותקן על ידם, וזאת על חשבונם ובתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

71. ברי כי הכרעתי דלעיל היא בשאלת הסגת הגבול, כאשר הדיון בשאלת הבעלות הוא בגררא על כל המשתמע מכך.

המצלמה-

72. דהן טענו כי המצלמה הותקנה על קיר המרפסת שלהם המהווה קיר פרטי. אין לקבל את הטענה כי מדובר בקיר פרטי. כל קירותיו החיצוניים של הבית המשותף הם קירות משותפים, וראו בעניין זה את הגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין.

73. תופעת הצבתן של מצלמות אבטחה ברכוש המשותף הפכה לאחרונה לחזון נפרץ. בניגוד למה שהיה נהוג בעבר, מצלמות אבטחה מותקנות כיום כמעט בכל מקום, במקומות ציבוריים ובמקומות פרטיים, וחיוניותן של מצלמות אלה לשם הגנה על הרכוש ועל הביטחון ידועה. אף במקרה דנן, הצבת המצלמה על ידי דהן נועדה לאפשר לדהן לממש את זכות היסוד שלהם לחיות בדירתם וליהנות מקניינם.

74. סוגיית התקנת מצלמות ברכוש המשותף מצריכה הכרעה בשאלות לא פשוטות של זכויות יסוד, הן מתחום ההגנה על הקניין, והן מתחום ההגנה על הפרטיות. מטבע הדברים, לעיתים, זכויות אלו מתנגשות זו בזו, ויש למצוא את נקודת האיזון המדויקת ביניהן. מובן, כי נקודת איזון זו שונה ממקרה אחד למשנהו, ויש לבחון כל מקרה לגופו וכל מאורע בהתאם לנסיבותיו.

75. פרק ו' לחוק המקרקעין הוא הפרק העוסק בבתים המשותפים נועד להסדיר את הזכויות שיש לכל בעל דירה בבית המשותף, ולהתוות את יחסי השכנות בין בעלי הדירות כתוצאה מהיותם "שותפים על כורכם" בחלקים שונים בבית המשותף. ככלל, חוק המקרקעין מעניק לכל בעל דירה מקסימום זכויות בקניינו, אך גם מחייב אותו למקסימום ההתחשבות בקניינו של שכנו. בתוך כך, קבע חוק המקרקעין מנגנונים שנועדו לעגן את הזכות הקניינית של בעל דירה בבית משותף הן בדירתו והן ברכוש המשותף, תוך הכפפתה לזכויותיהם של בעלי הדירות האחרים, ולהסדרים שכל בעלי הדירות קבעו ביניהם.

76. שני עקרונות בסיסיים ביחסי בעלי הדירות בבית המשותף בנוגע לרכוש המשותף, מצויים בסעיף 55 לחוק המקרקעין ובסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק.

77. סעיף 55 לחוק מבהיר כי הבעלות ברכוש המשותף הינה בידי כל בעלי הדירות, תוך שהוא קובע כי: "לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף...". סעיף 2(א) לתוספת הראשונה קובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו, או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, 'פגיעה ברכוש המשותף' – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

78. מהוראות חוק אלו עולה, כי הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות, ועל כן בעל דירה אחת אינו יכול לפגוע בו, אלא אם קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.

79. יחד עם זאת, הלכה פסוקה היא כי לא כל שימוש ברכוש המשותף מהווה "פגיעה", המצריך את קבלת הסכמת האסיפה הכללית. בשורה של פסקי דין שבראשה פסק הדין בע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645, נקבע כי שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, וממילא אינו דורש הסכמת בעלי הדירות. כך נקבע בפסק דין וינטרס הנ"ל:

"לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית המתירה אותו. נראה לי, כי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים".

80. הלכה זו עולה בקנה אחד עם ההוראה בסעיף 31(א) לחוק המקרקעין (החלה גם על בתים משותפים מכח סעיף 53 לחוק), לפיה: "באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים – (1) להשתמש במקרקעין שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר".

81. הנה כי כן, שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, ובעל דירה בבית המשותף רשאי לבצע שימוש כזה, גם אם לא קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.

82. ומהו אותו שימוש סביר? מובן, כי לכך לא ניתן ליתן תשובה חד ערכית. יש ששימוש מסוים ייחשב סביר ורגיל במקום מסוים, ואילו במקום אחר, אותו שימוש בדיוק יחשב שימוש חריג. התשובה לשאלה מהו "שימוש סביר", תוכרע, בסופו של דבר, בהתאם למקום, לזמן ולנוהג המקובל. וראו בעניין את דבריו של א. איזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי - בתים משותפים, תשס"א – 2001) 101.

83. כאמור, השאלה מהו שימוש סביר היא שאלה תלויה זמן, נוהג ומקום. על כן, לשם הכרעה בשאלה זו, שומה עלינו לבדוק את טיבה ותפקודה של המצלמה, את הפגיעה שנגרמת ליוסף, ואת הטעם להצבת המצלמה על ידי דהן.

84. בענייננו, עסקינן בהצבת מצלמה על קיר המצוי בהיקף שטח המחלוקת וסמוך לכניסה לדירת דהן. כאמור לעיל, קיר זה הוא רכוש משותף, ואין גם חולק כי דהן לא קבלו את הסכמת האסיפה הכללית להצבת המצלמה. מן העבר השני, אין ספק כי הצבת המצלמה על ידי דהן מספקת הגנה וביטחון לדהן ואינה מונעת שימוש דומה מיוסף. ואולם, בביקור שקיימתי במקום נוכחתי לראות כי המצלמה מופנית לכיוון המעלית, שם מצויה גם הכניסה לדירת יוסף. נכון להיום קיים שער התוחם את שטח המחלוקת. שער זה מתנשא לגובה של כ-170 ס"מ ומגביל את יכולת הצילום של המצלמה, באופן שלטעמי, כיום, היא פוגעת באופן מינימאלי בפרטיות של יוסף, אם בכלל. יחד עם זאת, משהוריתי על הסרתו של השער לא תהיה עוד הגבלה על יכולת הצילום של המצלמה. עדשת המצלמה תוכל לקלוט כל תנועה מדירת ואל דירת יוסף ויהיה בכך כדי לפגוע בפרטיות של יוסף. לאור האמור, על מנת שהתקנתה תהווה שימוש סביר גם בנסיבות הסרת השער, וממילא לא תצריך הסכמה של האסיפה הכללית או של יוסף, אורה על העתקתה לתוואי אחר אשר יהווה שימוש סביר לאחר הסרת השער.

85. למסקנה דומה נגיע גם מניתוח הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. חוק זה אוסר על פגיעה בפרטיות, ופגיעה בפרטיות על פי חוק זה היא, בין היתר, "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד".

86. העתקתה של המצלמה כפי שיפורט להלן תביא לידי כך שהכניסה לדירת יוסף לא תצולם ותצולם רק הכניסה לדירת דהן. ממילא, לא יהא ניתן לראות בפעולה זו צילום בשטח רשות היחיד, וממילא לא ניתן לטעון לפגיעה בפרטיות במקרה דנן. ודוק: אכן, זכות הפרטיות הינה זכות יסוד, המעוגנת אף בסעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואולם, לאור המוסבר, אין לראות ביוסף כמי שפרטיותם נפגעה כתוצאה מהצבת המצלמה על קיר משותף, בכפוף להסטתה כאמור.

87. סיכומי של דבר, גם בהקשר לחוק הגנת הפרטיות, אני סבורה כי במכלול האיזונים, ובהתחשב באופייה של הפגיעה, אם בכלל, יש להעדיף את האינטרס של דהן להגן על שלוות חייהם ורכושם, החוסה, כמובן, אף הוא תחת חוקי היסוד המוזכרים לעיל, ולהתיר להם להתקין את המצלמה תוך שמירה על פגיעה מינימאלית ביוסף, כמפורט לעיל.

88. לאור האמור, אני מורה לדהן להסיר את המצלמה או להעתיקה לקיר המקביל לקיר בו היא מותקנת או לקיר מעל דלת הכניסה לדירתם, באופן שהמצלמה לא תופנה לכיוון המעלית או לכיוון דלת הכניסה לדירת יוסף, והיא תוכל לצלם אך את הבאים לדירת דהן. הסרתה או העתקתה תיעשה בתוך 30 יום מהיום.

89. כפי שתואר בהרחבה בממצאי הביקור במקום לעיל, בחדר האמבטיה של יוסף קיים חלון לתליית כביסה אשר מחוצה לו מותקן מתלה לתליית כביסה המשמש אותו. מעדויות הצדדים וכן מתכתובת מייל שהוגשה וסומנה נ/14 עלה כי מיד לאחר שהקבלן התקין בדירת יוסף מתקן הכביסה הסירו יוסף את המתקן והתקינו תחתיו מתקן גדול יותר אשר בשל מידותיו "התקרבו" לחלון דירת דהן, אשר נמצא על קיר בניצב לקיר עליו הותקן המתלה. לאור דרישת הקבלן הוסר המתקן הגדול והוחזר המתקן המקורי למקומו. על מנת למנוע מיוסף לשוב ולהחליף את מתקן הכביסה באחר גדול יותר הסיטו דהן את המזגן שלהם לכיוון המתלה באופן הגודר אותו ומונע החלפתו במתקן גדול יותר.

90. היות ומדובר על התקנת מזגן על קיר חיצוני הרי שחלים על התקנה זו דיני השימוש הסביר ברכוש המשותף ולאחר שביקרתי במקום נחה דעתי כי על אף שהמזגן הוסט הצידה בכ-30 ס"מ, המיקום בו הוא מותקן מהווה שימוש סביר, כזה אשר אינו טעון הסכמה של האסיפה הכללית. מהביקור ומהעדויות שוכנעתי כי המזגן פולט אוויר במקביל למתקן הכביסה ולא לעברו ולא הוכח לי כי אמור להיות מותקן בבית מסתור כביסה. משכך, אין מיקומו של המזגן מהווה פגיעה ביוסף ומדובר לטעמי בזוטי דברים. בעניין זה אין ליוסף להלין אלא על עצמם שהרי לולא החליפו על דעת עצמם את מתקן הכביסה שלהם למתקן גדול יותר ה"גולש" לכיוון חלון דירת דהן לא היו האחרונים מסיטים את המזגן נושא ההליך למיקומו הנוכחי.

91. לאור האמור מצאתי לדחות את התביעה הדורשת להורות על להסטתו של המזגן.

פתח שחרור עשן

92. פתח שחרור העשן מצוי בקומה הרביעית של המבנה בסמוך ליציאה מהמעלית. בחלקו התחתון של הפתח הותקנו לבני זכוכית אשר חוסמות את הנראות של חלון חדר השינה בדירת דהן המצוי מאחורי אותו פתח. הפועל היוצא הוא שלמעלה ממחצית שטח החלון נחסם. יוסף טענו כי הדבר מהווה מפגע בטיחותי ומשכך יש להורות לדהן לפרק את לבני הזכוכית.

93. מעדות הגב' לשניאק, אדריכלית הבניין, בעניין עלה כי פתח שחרור העשן הכרחי, הן לצורך קבלת טופס 4 והן על מנת שהביטוח יתפוס במקרה של אירוע ביטוחי, ראו עדותה בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 1-5. מעדותה עלה כי פתח זה מתוכנן בהתאם להוראות יועץ בטיחות ולא ניתן להסתפק במילוט עשן דרך פתח אחר המשמש למילוט, ראו עדותה בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 31-39.

94. לאור עדותה של הגב' לשניאק, אשר לא הוכחשה, נכון לטעמי להורות על פירוק לבני הזכוכית והשבת הפתח לגודלו המקורי. יחד עם זאת, כחלק מהשיקולים למתן הצו לקחתי בחשבון שני שיקולים:

95. האחד, שלא ניתן לייחס את המעשה לחובת דהן, שכן יוסף בעצמו העיד כי אינו יודע מי ביצע את החסימה של הפתח לשחרור עשן, ראו עדותו בעמ' 37 לפרוטוקול שורות 36-37. הקבלן העיד כי הוא זה שהתקין את לבני הזכוכית בפתח שחרור העשן, ראו עדותו בעמ' 23 לפרוטוקול שורות 5-8, ודהן העידה כי היא לא דרשה או הנחתה את הקבלן לסגור את פתח שחרור העשן, אך היא מתנגדת לכך שייפתח היות ובתוכניות שצורפו לחוזה המכר שלה לא קיים פתח שחרור עשן במיקום הקיים כיום, וקיומו של פתח זה פוגע בפרטיות בחדר השינה של ביתה.

96. השני, שלא נבחנה האפשרות ליצור פתח שחרור עשן בעל מידות אורך ורוחב שונות במיקום דומה, אשר יתנו סה"כ שטח שחרור עשן דומה, אשר יפגע פחות בפרטיותה של דהן. ויובהר- על דרישות שירותי כיבוי אש לא ניתן לוותר, וככל שלא ימצא פתרון תקני אחר שיהא מקובל על בעלי הדירות בבית לא יהיה מנוס מהחזרת פתח שחרור העשן הקיים למתכונתו המקורית (טרם צמצומו). יחד עם זאת, אין מניעה שהקבלן יבחן מול שירותי הכבאות חלופות אחרות שיהא בהן כדי לענות על צרכי דהן מבלי לפגוע בתכליתו המקורית של הפתח הרלבנטי. ויוטעם, כל פיתרון שיבוצע בשטח יהא כפוף לקבלת אישור כדין של הגופים האמונים על נושא הבטיחות של המבנה.

97. לאור האמור, והיות והקבלן אינו צד להליך אינני עושה צו בעניין, אך טוב יעשה הקבלן אם יפעל בהתאם להוראותיי לעיל בתוך 60 יום מהיום.

98. בשים לב לעובדה שרק שניים מתוך ארבעה סעדים התקבלו אני מחייבת את דהן לשלם ליוסף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪.

99. לא מצאתי לחייב או לזכות את נתבעים 2-8 בהוצאות כלשהן. לאור העובדה שבתשריט יוסף- קבלן נכתב על גבי שטח המחלוקת "שטח משותף" ברי כי נתבעים אלו היו צד ראוי להליך, ושמורה הייתה להם הזכות להתייצב או לוותר על זכותם לטעון תוך מתן הודעה כי כל פסק דין שיינתן יהא מקובל עליהם.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יג' בסיון התשע"ה (31.5.15).
העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין